

1520096-25.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227501/2021 - 34º D.P. MORUMBI, 19760017 - 34º D.P. MORUMBI, 2087/21/338 - 34º D.P. MORUMBI, 2227501 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520096-25.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520096-25.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227501/2021 - 34º D.P. MORUMBI, 19760017 - 34º D.P. MORUMBI, 2087/21/338 - 34º D.P. MORUMBI, 2227501 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER APARECIDO DE SOUZA DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

VAGNER APARECIDO DE SOUZA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de agosto de 2021, pela manhã, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Rua José Capobianco, nº 232, Vila Sônia, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 15 (quinze) porções contendo tetrahydrocannabinol, substância conhecida como "maconha", pesando 50 g (cinquenta gramas), e 37 (trinta e sete)

porções de cocaína, pesando 10,5 g (dez gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou defesa prévia, subscrita por Defensor constituído nos autos (págs. 94/101).

Recebida a denúncia (págs. 129/133), durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Em seguida, diante da prova produzida sobreveio aditamento à denúncia, atribuindo ao acusado a causa de aumento de pena consistente em crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, recebido após manifestação da Defesa.

Nesta data, o acusado foi novamente interrogado, tendo em vista requerimento formulado pela Douta Defesa.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia e aditamento oferecidos.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereu: desclassificação da conduta denunciada para a prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06; redução da reprimenda por força do que estabelece o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06; fixação de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena; substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos; afastamento da agravante consistente em crime praticado em período de calamidade pública, afastamento da causa de aumento de pena objeto do aditamento; compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea; e, por fim, direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 06 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 07/09); auto de exibição e apreensão (pág. 33); laudo de constatação (págs. 24/27); laudo de exame químico-toxicológico encartado às páginas 163/165, que apontou para a presença de tetrahydrocannabinol e cocaína nas substâncias analisadas; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado admitiu amplamente a traficância.

Em solo policial, ainda no calor dos fatos, perante a d. Autoridade Policial e na presença de seu advogado, Dr. Mário Leão Benzadon (págs. 08 e 12), esclareceu que: "(...) é dependente químico há mais de 30 anos e que na data dos fatos estava vendido drogas visto estar passando necessidade financeira. Que comprou as referidas drogas na comunidade do Paraísoópolis. Sem mais." (pág. 12).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, retificou a versão apresentada durante a fase investigativa.

Disse agora que estava no local montando uma barraca para vender água de côco.

Afirmou que tinha um sócio, portava uma máquina, e estava arrumando a barraca.

Foi surpreendido por um indivíduo que lhe pediu um pino de cocaína. Portava cinco porções da droga para seu consumo e cedeu uma delas ao suposto usuário, embora não o conhecesse. Em seguida esse rapaz lhe deu voz de prisão em flagrante, afirmando que era policial e portava uma arma de fogo.

Esse rapaz chamou os outros dois policiais e deixou o local. Em seguida foi conduzido ao distrito policial.

Acrescentou que não portava dinheiro e nem mesmo outras drogas, mas apenas os cinco pinos de cocaína para consumo.

Negou ter mantido contato com outros indivíduos, servido ou recebido qualquer coisa de outras pessoas.

Disse que tem um sócio nessa atividade que iria começar a exercer naquele dia; no momento em que foi abordado ainda estava sozinho, mas um caseiro teria presenciado a abordagem policial.

Foi levado para a delegacia e a máquina e os produtos que portava para iniciar a

venda de água de cocô ficaram no local e não foram apreendidos pelos policiais. Negou ter confessado o crime por ocasião de sua prisão em flagrante. Referida exculpatória, entretanto, não é merecedora de nenhuma credibilidade, restou isolada nos autos e desacompanhada de demonstração probatória de veracidade, sendo mesmo infirmada pela prova adversa. Entretanto, novamente interrogado, o acusado admitiu o cometimento do crime. Disse agora que é viciado no consumo de drogas há aproximadamente vinte anos, enfrentava dificuldades financeiras e naquele dia portava os entorpecentes para fins de mercancia. Foi abordado por policiais e as drogas foram encontradas em seu poder.

O que se verifica é que a minudente confissão levada a efeito pelo réu em solo policial, oportunidade em que estava acompanhado de advogado, bem como a versão que apresentou na presente audiência, encontraram mesmo o necessário conforto em tudo quanto produzido ao longo da persecução criminal, não enfrentando qualquer resistência no contexto probante, que o compromete sobremaneira.

É que os policiais civis responsáveis pela diligência apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Narraram, em uníssono, de forma bastante serena e insuspeita, que receberam denúncia versando sobre tráfico de drogas.

Dirigiram-se ao local indicado na denúncia, posicionaram-se a uma distância aproximada de 50 metros, e passaram a observar, o que fizeram quinze minutos. Esclareceram que o local era um campo de futebol, o réu estava na parte externa, notaram que ele foi procurado por alguns indivíduos, viram quando ele serviu algo a eles e recebeu dinheiro em troca, o que se deu por duas ou três vezes. Desta forma, o abordaram e o revistaram e encontraram em poder dele uma sacola plástica contendo 15 porções de maconha e 37 pinos cocaína, bem como a quantia de R\$50,00 em notas trocadas.

Acrescentaram que durante a campana notaram que quando o acusado retirava algo dessa sacola e servia os indivíduos, recebia o dinheiro, que guardava na mesma sacola.

Questionado, informalmente, o acusado confessou a prática da traficância, justificando que enfrentava dificuldades financeiras, disse que estava vendendo drogas há dois e recebia a quantia diária de R\$200,00 (duzentos reais).

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime, sendo incontroversa a autoria.

Preso em flagrante delito e conduzido ao distrito policial, o acusado admitiu amplamente a imputação.

Referida confissão se mostrou absolutamente espontânea e em perfeita consonância com os demais elementos de prova coligidos, não havendo daí qualquer motivo para que seja desprezada.

Em Juízo, entretanto, na primeira oportunidade em que foi inquirido, o réu negou a responsabilidade pela droga apreendida, oferecendo singela negativa de autoria, cuja veracidade nem de longe comprovou, como a essa altura lhe competia fazer, nos termos do que prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Entretanto, novamente interrogado, o acusado admitiu amplamente a imputação.

E os policiais inquiridos, de forma absolutamente serena e insuspeita, deram conta da diligência encetada, motivada que foi pela denúncia de que no local dos fatos estaria ocorrendo a venda de substâncias entorpecentes, que culminou com a prisão em flagrante do acusado, em poder de dele localizaram substâncias entorpecentes fracionadas e diversificada.

Sendo assim, ratificaram integralmente as circunstâncias do flagrante, tais como articuladas na denúncia.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente, que sequer conheciam.

Como qualquer testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”.(TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Enfim, o conjunto probatório é bastante sólido e incrimina sobremaneira o réu, ensejando uma condenação segura.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como os tóxicos estavam acondicionados – 15 trouxinhas plásticas contendo maconha, e 37 eppendorfs contendo cocaína – e as circunstâncias da prisão afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei Especial, até porque o acusado não reivindicou a posse das drogas para consumo próprio.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: “Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (TJSP – AC 9.751-3 – Rel. Gonçalves Sobrinho – RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente – Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização – Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível – Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT – AC 565/86 – Rel. Mauro José Pereira – RT 620/331).

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Acolho a r. Manifestação oferecida pela Douta Defesa, para afastar a causa de aumento de pena objeto do aditamento oferecido.

Com efeito, como sustentou o ilustre Dr. Defensor, o fato ocorreu em período de pandemia, ocasião em que atividades escolares estavam suspensas presencialmente.

Ademais, não há prova segura de que na data do crime as atividades esportivas estavam sendo realizadas no local, de forma que a dúvida formada fica resolvida em favor do acusado.

A causa de aumento de pena em questão tem a finalidade de alcançar as pessoas que frequentam os locais determinados no dispositivo legal em questão, de forma que não havendo provas nesse sentido, de rigor o não acolhimento da pretensão ministerial.

Demonstrada a ocorrência do delito, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão juntada às págs. 86/88 demonstra que o acusado registra condenação definitiva por crime de tráfico de drogas, oriunda de processo que tramitou perante a 1ª vara Criminal desta capital, cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 19/06/2017, que configura reincidência.

Logo, pelos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Incidu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumpra salientar, que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 – circunstância objetiva -, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade

social. Ademais, o acusado praticou crime que compromete a saúde pública, já extremamente abalada pela pandemia.

Todavia, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Pela reincidência comprovada, agravo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Em se tratando de réu reincidente, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção no que diz respeito à dosimetria da pena, por força da circunstância agravante da reincidência.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.

TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade.

Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.". (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra VAGNER APARECIDO DE SOUZA DIAS, R.G. nº 23.761.824, e o condeno ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos e oitenta e três dias multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando afastada a majorante objeto do aditamento oferecido, prevista no artigo 40, inciso III, da mesma lei, fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO,

tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da Lei 8.072/90, bem como por força da reincidência comprovada, nos termos do que estabelece o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Em razão da gravidade do crime, considerado hediondo, e pela comprovada reincidência, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Ademais, trata-se de réu reincidente, de forma que referido benefício encontra expressa vedação legal. Por essas mesmas razões, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que persistem as razões que fundamentaram a decretação da medida, reforçadas que foram pela prova produzida no contraditório, o que se mostra necessário como forma de se resguardar a saúde pública e a aplicação da lei penal (artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro relacionada no boletim de ocorrência - R\$ 50,00 - uma vez que oriunda da venda de drogas.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA